

1002825-61.2022.8.26.0572

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor vítima de roubo de cartão e celular. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Danos materiais configurados com relação às transferências via 'PIX', reconhecidas como fraudulentas. Restituição é de rigor. Danos morais. Banco réu foi informado da ocorrência do roubo no mesmo dia das transações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002825-61.2022.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002825-61.2022.8.26.0572

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Paloma Ignácio Bonato

Requerido:

Nubank S/A (Nu Pagamento S.a - Instituição de Pagamento) e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por PALOMA IGNÁCIO BONATO em face de NU PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Narra a autora que é cliente dos bancos requeridos e, em 07/08/2022, teve seu aparelho de celular furtado e invadido por criminosos, os quais subtraíram quantias das contas de titularidade da requerente nos bancos réus, causando prejuízo de R\$ 14.079,14. Ressalta que tentou a resolução do problema com os requeridos de forma consensual, porém não obteve êxito. Ao final, requereu a procedência da ação, com restituição dos valores subtraídos, além de indenização por danos morais (fls. 01/16). Juntou documentos (fls. 17/45).

A decisão fls. 54 deferiu a gratuidade judiciária.

O requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A apresentou contestação pleiteando a impossibilidade da inversão do ônus probatório; refutou a existência de falha na

prestação de serviços, pois houve fortuito externo. Por fim, pugnou improcedência dos pedidos iniciais, pois não há qualquer ato ilícito e nexos causal, estando configurada a culpa exclusiva da autora, bem como pela ausência de provas de maiores abalos psíquicos aptos a embasar uma indenização por danos morais ( fls. 102/119). Juntou documentos (fls. 120/130).

A requerida NU PAGAMENTOS S.A- INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, em seu turno, contestou e destacou a inexistência de falha na prestação de serviços. Discorreu que a autora demorou para informar o furto do celular, além de estar configurado o fortuito externo. No que tange aos danos materiais, relatou que as transações mencionadas pela autora perfazem o montante de R\$ 9.570,00, e não de R\$ 10.079,14, bem como a requerida conseguiu recuperar a quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais). Quanto aos danos morais, ressaltou que eventual sofrimento suportado pela autora não decorrem de ato do NuBank, motivo pelo qual devem ser afastados ( fls. 131/153). Juntou os documentos de fls. 154/215.

Réplica. (fls.219/228)

Indicação de provas. (fls. 235/240 - 241 - 242)

É o relatório. Fundamento e Decido.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito desafia o julgamento antecipado, na esteira do que prevê o art. 355, I, do CPC.

Inicialmente, não obstante a alegação da cooperativa de que não se aplica a inversão do ônus probatório quanto a ela, a tese não deve ser acolhida. Com efeito, as Cooperativas de Crédito são consideradas instituições financeiras, permanecendo sujeitas ao controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, nos moldes dos artigos 17 e 18, §1º, da Lei 4.595/64, equiparandose aos bancos, de modo a aplicar o entendimento da Súmula nº 297 do C. STJ.

Assim, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, conforme o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"MONITÓRIA - Cédula de crédito bancário - Abertura de crédito Hipótese em que a cooperativa atua como instituição financeira no oferecimento de crédito - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Não obstante, a necessidade de afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor para que se cogite a anulação de cláusulas - Cerceamento de defesa não configurado - Documentos apresentados suficientes para verificação da regularidade da cobrança e de seus encargos, no período considerado, não havendo necessidade de produção de outras provas ou inversão do ônus probatório, em vista das provas coligidas Ausência de limitação dos juros contratuais - Possibilidade de Capitalização de juros - Sentença mantida - Recurso não provido." (TJSP, Apelação nº 0002218-60.2015.8.26.0653, Relator Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2017).

Pois bem.

Em que pesem as defesas apresentadas, não há dúvidas de que a autora tenha sido vítima de furto de celular, o que vem corroborado pelo boletim de ocorrência de fls. 18/20, sendo crível que fraudadores realizaram as transações impugnadas, sobretudo porque a consumidora estava desprovida dos meios necessários para tanto, tendo havido falha no sistema de segurança digital das instituições rés.

Note-se que os sistemas das instituições financeiras podem ser seguros, mas isto não significa serem infalíveis, tanto que as fraudes bancárias existem e não são poucas. Ademais, a tecnologia denominada "Pix" veio para facilitar a realização de transações bancárias, mas já é objeto de inúmeras fraudes, conforme amplamente noticiado (artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil).

Nesse diapasão, não há, no caso dos autos, documento que comprove, de forma cabal e indiscutível a efetiva realização das transações pela consumidora, sendo necessário lembrar que, tratando-se de relação de consumo, incumbia ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, não é por outro motivo que a jurisprudência acerca do tema ressaltou que, em tais situações, fica o

"(...) Ônus da prova a cargo do Banco, pois se alega que foi o cliente que retirou o dinheiro deve estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência" (TJSP – 11ª Câmara de Direito Privado – Ap 1042746-66.2014.8.26.0100/São Paulo – Rel. Des. Gilberto dos Santos – j. 23.10.2014).

Ademais, em situação que também envolvia a realização de pagamentos e transferências em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça afirma que o ônus da prova cabe à instituição bancária:

"(...) – É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. – Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. – Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. (...)" (STJ – 3ª T. – REsp 727.843/SP – Relª. Minª. Nancy Andrighi – j. 15.12.2005 – DJU 01.02.2006, p. 553 – RDDP 40:145 – sem destaque no original).

No mesmo sentido, em casos específicos envolvendo transação via "Pix", confira-se:

"Apelação - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de não fazer, responsabilidade civil e tutela antecipada - Procedência - Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante - Realização de transferências via PIX também não reconhecidas pelo autor - Existência e legitimidade destas transações não evidenciadas, sendo comprovada a fraude na sua realização - Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade destas operações - Ausência de prova para tanto - Cabível a devolução dos valores descontados indevidamente do demandante - Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil - Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece ser mantido - Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso improvido." (TJSP – 14ª Câmara de Direito Privado – Ap 1015912-82.2021.8.26.0002/São Paulo – Rel. Des. Thiago de Siqueira – j. 01.09.2021);

"ACÓRDÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERENCIAS INDEVIDAS EMCONTA CORRENTE VIA PIX – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – AUSENCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A ALEGAÇÃO – PROVA DA AUSENCIA DE FRAUDE QUE COMPETIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO

MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (Colégio Recursal de Araçatuba – 1ª Turma Cível – Recurso Inominado 1006234-50.2021.8.26.0032/Araçatuba – Rel. Juiz José Daniel Dinis Gonçalves – j. 01.09.2021);

"CARTÃO BANCÁRIO - Ação de indenização por dano material e moral relativa à movimentação bancária com uso de cartão - Relação de consumo - Roubo do cartão e da senha - Transferências Pix, compras e empréstimo realizados antes do bloqueio do cartão - Transações efetuadas com a senha da autora, titular da conta, e fora do perfil de consumo dela - Nenhuma prova de zelo bancário para conter os sucessivos débitos - Dano material a ser ressarcido pela instituição, responsável pela guarda zelosa do numerário alheio - Dano moral, porém, não configurado - Recurso parcialmente provido." (Colégio Recursal de Penha de França – 1ª Turma Cível e Criminal – Recurso Inominado 1004513-47.2021.8.26.0005/São Paulo – Relª. Juíza Mara Regina D'Agnessa Trippo Kimura – j. 03.08.2021).

Consequentemente, a responsabilidade das instituições financeiras – que participaram da cadeia de transações fraudulentas descrita na inicial – resta mais do que configurada, uma vez que a legislação dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

Note-se que a legislação permite ao fornecedor comprovar que o serviço não é defeituoso quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, porém, nenhuma das excludentes de responsabilidade restou efetivamente demonstrada nos autos.

Ressalta-se, a alegação de que a autora demorou em noticiar o furto do celular, além de corroborar sua boa-fé e confiança no sistema de segurança das instituições, justifica-se diante do episódio criminoso, que, por certo, deve ter abalado a vítima, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade daquelas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"CELULAR FURTADO. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS, VIA PIX, REALIZADAS PELO APLICATIVO DO CELULAR. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO FURTO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DO FORNECEDOR EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE PAGAMENTOS QUE EVITE A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS POR TERCEIROS QUE NÃO O TITULAR DA CONTA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Falha na prestação do serviço consistente na falta de segurança do aplicativo de celular para realização de transferências. 2. Ressarcimento a que faz jus o consumidor prejudicado pela falha do aplicativo, a despeito da demora em comunicar o furto. 3. Danos morais não configurados. 3. Recurso inominado que se conhece e ao qual se dá parcial provimento, nos termos da fundamentação." (Colégio Recursal Central da Capital – 7ª Turma Cível – Recurso Inominado 1009599-63.2021.8.26.0016/São Paulo – Relª. Juíza Clarissa Rodrigues Alves – j. 12.08.2022).

Ademais, ainda que se concluisse que a vítima colaborou culposamente para a prática do golpe, isto somente serviria para eventual caracterização de culpa concorrente, o que, como se sabe, não exime a responsabilidade dos fornecedores.

Realmente, cabe destacar que tal situação representaria hipótese de "(...) Culpa concorrente que não é hábil a romper o nexo de causalidade nas relações de consumo" (TJSP – 19ª Câmara de Direito Privado – Ap 1065437-64.2020.8.26.0100/São Paulo –

Rel<sup>a</sup>. Des<sup>a</sup>. Claudia Grieco Tabosa Pessoa - j. 26.07.2021).

No mesmo ínterim: "(...) Por não se enquadrar como excludente de responsabilidade, a concorrência de culpas não é suficiente para afastar o dever (...) de indenizar pelos danos morais e materiais configurados" (STJ - 3<sup>a</sup> T. - REsp 1.139.997/RJ - Rel<sup>a</sup>. Min<sup>a</sup>. Nancy Andrighi - j. 15.02.2011 - DJe 23.02.2011).

E nem se argumente a existência de fato de terceiro, na medida em que a atuação de terceiro fraudador insere-se no âmbito de fortuito interno, que não pode ser alegado para eximir sua responsabilidade (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 181-182).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

"(...) Na relação de consumo, existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal" (STJ - 4<sup>a</sup> T. - REsp 762.075/DF - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - j. 16.06.2009 - DJe 29.06.2009).

E ainda: "(...) A exclusão da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado" (STJ - 3<sup>a</sup> T. - REsp 759791/RO - Rel. Min. Sidnei Beneti - j. 03.04.2008 - RSTJ 211:277).

Por fim, dispõe a Súmula 479 do Tribunal da Cidadania: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, somente resta concluir que: "(...) Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC." (STJ - 3<sup>a</sup> T. - REsp 557.030/RJ - Rel<sup>a</sup>. Min<sup>a</sup>. Nancy Andrighi - j. 16.12.2004 - DJU 01.02.2005, p. 542).

Destarte, afigura-se inafastável a responsabilidade das instituições bancárias rés, sendo que, deverão arcar com os prejuízos de ordem patrimonial causados ao consumidor.

Quanto à ré COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA PR/SP, prejuízo de ordem material corresponde ao montante de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se observa dos documentos de fls. 37/38.

No que tange à requerida NU PAGAMENTOS S.A- INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, os prejuízos suportados pela autora satisfazem o montante de R\$ 10.079,14 (dez mil e setenta e nove reais e quatorze centavos), sendo R\$ 5.070 (fls. 39/40) de saídas e R\$ 5.009,14 referentes ao adimplemento no "recarga play", já incluídos o valor original, juros e IOF (fls. 41/45).

Por fim, resta evidente a ocorrência de dano moral indenizável, primeiro pelos desfalques sucessivos de quantia bastante significativa da conta da consumidora, possibilitados pelas instituições rés, segundo por não ter seu problema solucionado, precisando mover a máquina judiciária para tanto, cuja situação ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor vítima de roubo de cartão e celular. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Danos materiais configurados com relação às transferências via 'PIX', reconhecidas como fraudulentas. Restituição é de rigor. Danos morais. Banco réu foi informado da ocorrência do roubo no mesmo dia das transações fraudulentas e orientou o apelante a procurar os meios judiciais. Danos morais fixados em R\$ 5.000,00. Razoável e proporcional ao dano causado. Sentença reformada. Sucumbência fixada inteiramente em face do réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP - 14ª Câmara de Direito Privado - Ap 1004258-95.2021.8.26.0003/São Paulo - Rel. Des. Benedito Antonio Okuno - j. 11.08.2021).

Em relação ao quantum indenizatório, considerando o abalo à honra objetiva da autora, a notória capacidade econômico-financeira das instituições réas, a insistência destas na defesa da prática de ato lícito e as diretrizes de atenuação dos transtornos causados, bem como a prevenção de novas condutas, reputa-se a quantia de R\$5.000,00, de forma solidária, como tutela jurisdicional satisfatória e razoável.

### III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

A) Condenar a NU PAGAMENTOS S.A na obrigação de restituição das operações realizadas indevidamente na conta da Autora, no montante de R\$ 5.070 (cinco mil e setenta reais), bem como cancelar a cobrança da fatura referente ao pagamento do "recarga play", na quantia de R\$ 5.009,14 (cinco mil e nove reais e quatorze centavos), já incluídos o valor principal, juros e IOF, com suas variações), ou ressarcir a autora, caso a fatura tenha sido adimplida (fls. 44). Acresce-se a correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação;

B) Condenar o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., na obrigação de restituição das operações realizadas indevidamente na conta da Autora, correspondente aos danos materiais no montante de R\$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e

C) Condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R\$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a presente data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), bem como acrescida de juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Oportunamente, archive-se.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, data e hora da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA